

1500321-63.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Comarca: Guararapes

Foro: Foro de Guararapes

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... do crime de associação para o tráfico, conforme será exposto mais adiante.

Confira-se a respeito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 40, INCISOS V E VII, DO CP E DA AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CP NO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guararapes

Foro de Guararapes

2ª Vara

Rua Luiz Lincoln de Oliveira s/n, Guararapes-SP - cep 16700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500321-63.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500321-63.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2055179/2021 - DEL.POL.GUARARAPES, 16449693 - DEL.POL.GUARARAPES, 250/21/215 - DEL.POL.GUARARAPES, 2055179 - DEL.POL.GUARARAPES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ÉDER MARCELO DE OLIVEIRA LOPES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE CALDAS NERY SOARES

Vistos.

ÉDER MARCELO DE OLIVEIRA LOPES e PATRÍCIA ALVES LAMEU, qualificados nos autos (fls. 05 e 06, respectivamente), foram denunciados como incurso nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, sob os conseqüências da Lei nº 8.072/90, porque, supostamente, entre 12 de agosto de 2020 e 25 de fevereiro de 2021, em horário incerto, na Rua Professor Benedito Pereira de Moraes, nº 591, Jardim Nova América, nesta cidade e Comarca de Guararapes/SP, com vontade consciente, associaram entre si para o fim de, reiteradamente, praticar o crime de tráfico ilícito de drogas.

Ainda, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta das 06h00min, na Rua Professor Benedito Pereira de Moraes, nº 591, Jardim Nova América, nesta cidade e Comarca de Guararapes/SP, os mesmos réus, com vontade consciente e agindo com unidade de propósitos, guardavam 3,06g (três gramas e seis centigramas) acondicionados em 22 (vinte e dois) pinos, tipo eppendorf, da droga Benzoilmetilecgonina, vulgarmente

conhecida por "Cocaína", e 98,74g (noventa e oito gramas e setenta e quatro decigramas) acondicionados em 04 (quatro) porções da droga Tetrahydrocannabinol, conhecida vulgarmente como "Maconha", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme exames químico-toxicológicos de fls. 37/39 e 40/42.

Os acusados foram notificados pessoalmente (fls. 181 e 183) e apresentaram defesa preliminar (fls. 205/206 e 218/219).

Ausentes as causas de rejeição do artigo 395 do CPP, a denúncia foi recebida em 09/09/2021 (fls. 226/227).

Irresignado com a decisão que recebeu a denúncia, a defesa técnica de EDER MARCELO DE OLIVEIRA LOPES interpôs Recurso em Sentido Estrito (fls. 242/244), alegando litispendência com o processo de nº 1500087-72.2021.8.26.0218, da 2ª Vara Judicial desta Comarca.

O órgão ministerial apresentou contraminuta de Recurso em Sentido Estrito às fls. 251/254.

À fl. 289 foi proferida decisão pelo não conhecimento do recurso interposto, por ausência de pressuposto recursal de cabimento e regularidade.

Não sendo o caso de absolvição sumária (artigo 397 do CPP), foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 226/227).

Na fase instrutória, foram ouvidas as testemunhas da acusação arroladas. Ao final, os réus foram interrogados.

Ausentes requerimentos de diligências complementares (artigo 403 do CPP), as partes ofereceram alegações finais escritas (fls. 322/335, 347/358 e 384/398).

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO (artigo 93, inciso IX, da CRFB/88).

De proêmio, afasto as preliminares arguidas pela defesa acerca da litispendência, conexão e continência.

No caso em comento, os acusados estão sendo processados em duas ações, mas por fatos distintos. Nos autos de nº 1500087-72.2021.8.26.0218, os réus Éder Marcelo de Oliveira Lopes e Patrícia Alves Lameu foram denunciados por terem se associado com outras pessoas em período anterior ao dia 12 de agosto de 2020.

Por outro lado, no presente processo, ambos foram denunciados por terem se associado entre 12 de agosto de 2020 até 25 de fevereiro de 2021.

Nesse sentido, em que pese haver a imputação pelo mesmo crime, o momento consumativo é diverso, motivo pelo qual não há que se falar em "bis in idem", devendo persistir ambas as ações penais em curso.

Outrossim, no que tange a alegação de conexão e continência o Ministério Público propôs ações penais diferentes, conforme já fundamentado, para evitar tumulto processual, já que nestes autos constam como denunciados apenas Éder Marcelo e Patrícia, ao passo que nos autos de nº 1500087-72.2021.8.26.0218 há inúmeros denunciados e somente pelo crime descrito no artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

No mais, cumpre consignar que a referida preliminar já foi analisada e rejeitada, razão pela qual remeto à decisão de fls. 226/227.

Não havendo nulidade a sanar, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

Trata-se de ação penal visando apurar a prática do crime de tráfico de entorpecentes e a associação para o tráfico de drogas.

A ação penal é PROCEDENTE.

No âmbito da materialidade, a prova é constituída pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02); boletim de ocorrência (fls. 13/16); auto de exibição e apreensão (fls. 17/18); laudos periciais nos entorpecentes (fls. 37/39 e fls. 40/42); investigações realizadas nos aparelhos celulares apreendidos (fls. 134/141); e, em conformidade com o disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal, pela prova oral colhida.

A autoria dos crimes, por sua vez, está devidamente comprovada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre os ora réus de forma certa e segura.

A testemunha Elias Pichirilo Junior, policial civil, ouvida em sede policial (fl. 03), informou que, acompanhado pela Equipe 4, durante a Operação denominada Fox 01,

cumpriu mandado de busca e apreensão na cada dos acusados. Na residência, localizaram Éder Marcelo de Oliveira Lopes e Patrícia Alves Lameu. Havia prévia notícia da polícia local acerca da traficância por ambas as pessoas. Indagado, Éder informou quanto à existência de drogas em um quarto dos fundos, utilizado como dispensa. Foram localizados 04 (quatro) pequenos tabletes de substância gramínea esverdeada, aparentando tratar-se de maconha e uma balança de precisão em funcionamento. Novamente indagado, negou a existência de outras substâncias. Entretanto, em buscas no interior da residência, no quarto da frente, em uma gaveta da cômoda, sob as roupas, foram localizados 22 (vinte e dois) microtubos, do tipo eppendorf, contendo substância esbranquiçada, em pó, aparentando tratar-se de cocaína. Assim, foi dada voz de prisão aos indiciados. Em juízo (mídias audiovisuais), reiterou a versão. Acrescentou que o acusado assumiu a propriedade e que parte era para a venda e outra parte para consumo.

A testemunha Daniel Rodrigo Martins da Silva, policial civil, ouvida em sede policial (fl. 04) e em juízo (mídias audiovisuais), reiterou a narrativa apresentada por seu colega de farda.

Registre-se, por oportuno, que em observância à determinação constitucional da razoável duração do processo, bem como do disposto na Resolução nº 105/2010 do CNJ, desnecessária a transcrição dos depoimentos. No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 5. O art. 405 do Código de Processo Penal possibilita o registro dos termos da audiência de instrução em meio audiovisual. Tal regra - cuja redação foi conferida pela Lei n.º 11.719/2008 - não tem o escopo somente de reduzir o tempo de realização do ato, em razão da desnecessidade da redução, a termo, dos depoimentos do acusado, vítima e testemunhas, mas, também o de possibilitar registro fiel da íntegra do ato, com imagem e som, em vez da simples escrita. Vê-se, assim, que o dispositivo não causa prejuízo às partes. Ao contrário, fortalece a sua segurança. 6. Por isso, corretamente, estabelece o art. 405, § 2º, do Código de Processo Penal, que, "no caso de registro audiovisual, será encaminhado às partes cópia do registro original, sem necessidade de transcrição". 7. A busca da celeridade na prestação jurisdicional é hoje imperativo constitucional, estabelecido no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, segundo o qual "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação." O fato de não terem sido gravados e transcritos depoimentos orais alinhou-se ao espírito da referida norma constitucional. 8. No mais, se ao Julgador ocorre a necessidade de ter acesso ao conteúdo dos depoimentos gravados em meio audiovisual, pode fazê-lo com o auxílio de uma miríade de equipamentos, dispensada efetivamente a degravação. 9. O Poder Judiciário brasileiro, a bem de todos, tem buscado nos recursos tecnológicos meios para otimizar a prestação jurisdicional, devendo se harmonizar com este horizonte todos aqueles que nele atuam. (...)" HC 177195 / SP. Também: (...) 1. A mens legis do artigo 405 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 11.719/08, consiste em impor como regra o registro dos depoimentos por meios ou recursos de gravação, dentre os quais se declina o audiovisual, afastando-se a necessidade de sua transcrição. RHC 47283 / RS.

Tais testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, anotando-se que as palavras dos policiais civis se revestem de coerência, robustez e segurança e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou falsidade, devendo ser aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando os acusados, então, o ônus de contrastá-las, o que não fizeram.

Com efeito, não se pode presumir que a ação dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais.

Nesse sentido:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser

sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam". (Des. Antônio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap. Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016).

O acusado Éder Marcelo de Oliveira Lopes, ouvido em sede policial (fl. 05), alegou ser proprietário dos 22 (vinte e dois) microtubos contendo cocaína e dos 04 (quatro) tablets de maconha. Parte da droga era para consumo pessoal e parte para a venda. Precisa vender para manter o vício e pagar os fornecedores. Não revelou o nome do fornecedor. Sua companheira Patrícia Alves Lameu não tem participação no tráfico de drogas. Patrícia tinha ciência das drogas em sua casa, mas acreditava que era apenas para consumo. Compra drogas em pouca quantidade e, vez ou outra, vende para seus amigos. Em juízo (mídias audiovisuais), renovou a narrativa. Disse que sua esposa nada tem a ver com os fatos.

A acusada Patrícia Alves Lameu, ouvida em solo policial (fl. 06), negou ser traficante. Toda a droga encontrada era de seu marido Éder Marcelo de Oliveira Lopes. Nunca ajudou o marido na venda de drogas. Sabe que Éder consome entorpecentes e vende pequenas porções para alguns amigos. Nunca pagou fornecedor de drogas para seu marido. Nunca ajudou embalar as drogas os preparar. Sempre repreendeu o marido quanto ao tráfico. Em juízo (mídias audiovisuais), modificou a versão. Negou a propriedade da droga, mas admitiu, após ser questionada sobre o conteúdo das conversas do celular, que ajudou o marido em algumas negociações. Como percebo, em que pese a negativa da ré quanto ao cometimento dos delitos, a sua versão encontra-se amplamente dissociada das demais provas coligidas aos autos, em especial dos depoimentos colhidos em juízo, bem como do relatório de fls. 134/141. Várias circunstâncias, devidamente demonstradas, conspiram para a formação de convicção no sentido da destinação mercantil da droga apreendida: (a) a natureza e quantidade do entorpecente; (b) a forma de acondicionamento do entorpecente; e (c) forma com que se deu a prisão dos acusados;

Assim sendo, todas essas circunstâncias da ação, somadas, demonstram a ocorrência da mercancia ilícita e impede o acolhimento da pretensão absolutória ou desclassificatória da defesa, não deixando dúvidas que o entorpecente era destinado ao comércio.

Como se sabe, o tipo penal incriminador à espécie se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma com as outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio.

Sendo impossível apurar em conjunto a sua integralidade, há de se ponderar todas as fases em que se desenvolve esta atividade, tendo a lei se contentado, no escopo de combater as toxicomanias, em admitir que qualquer uma delas, por si só, configura o crime de tráfico ilícito de drogas.

Além do mais, traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas" (RF 320/237).

Ainda, não há que se cogitar em desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06. A tese defensiva desclassificatória deverá passar necessariamente pela análise do parágrafo 2º, do artigo 28, da Lei de Drogas.

O §2º do artigo 28, da Lei de Drogas explica que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Sobre os critérios distintivos entre a tipificação do delito no art. 28 e art. 33

da Lei de Drogas, assim leciona Renato Brasileiro de Lima:

"1) natureza e a quantidade da substância apreendida: é evidente que o critério da natureza e da quantidade de droga apreendida não pode ser utilizado como fator exclusivo para se distinguir o tráfico do porte de drogas para consumo pessoal. Afinal, até mesmo para descaracterizar o tráfico de drogas, é muito comum que traficantes tenham à disposição pequena quantidade de drogas. (...) Ora, atento à realidade em que vive e observando aquilo que as regras de experiência deverão concluir que tal quantidade jamais poderia ser consumida por um único indivíduo. (...)

2) local e condições da ação: (...) Com efeito, se o agente for surpreendido em determinada localidade conhecida como ponto de distribuição de drogas, trazendo consigo a substância entorpecente acondicionada em pequenas embalagens para venda, sendo com ele apreendido grande numerário em dinheiro, provavelmente recebido dos usuários, demonstrando-se, ademais, uma constante movimentação de pessoas para o consumo e a aquisição de drogas, há de se concluir que se trata de tráfico de drogas;

3) circunstâncias sociais e pessoais: embora não seja um critério absoluto, leva-se em consideração a condição econômica do agente, no sentido de que a apreensão de grande quantidade de droga em poder de pessoa pobre seria um indicativo de traficância. (...) Ainda em relação às circunstâncias pessoais, convém destacar que a circunstância de ser o agente considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes, mormente quando comprovada a sua condição de traficante e considerável quantidade com ele apreendida.

4) conduta e antecedentes do agente: (...) A nosso ver, se é verdade que os antecedentes do agente, isoladamente considerados, não podem ser utilizados para aferir se se trata de tráfico ou porte de drogas para consumo pessoal, também não é menos verdade que, em conjunto com os demais critérios apontados pelo art. 28, §2º (v.G., natureza e quantidade de droga apreendida), não há qualquer óbice à utilização dos antecedentes como mais um critério indicativo de possível traficância. Deveras, se o agente foi flagrado transportando várias pedras de crack em conhecido ponto de venda de drogas, ostentando condenações anteriores pelo crime de tráfico de drogas, parece não haver dúvidas de que seus maus antecedentes podem ser utilizados pelo magistrado como mais um critério indicativo da finalidade de mercancia. Enfim, desde que analisados em conjunto com demais critérios de aferição de consumo pessoal, os antecedentes do acusado podem ser sopesados pelo magistrado para o correto enquadramento típico, sem que se possa objetar que isso caracteriza um retorno indevido ao Direito Penal do autor." (Legislação criminal especial comentada: volume único. 9 ed. rev., atual. e ampl. Salvador: JusPODIVM, 2021, fls. 1038 a 1040).

De acordo com o caso em tela, foi constatado, na residência dos acusados, que estes guardavam 3,06g (três gramas e seis centigramas) acondicionados em vinte e dois pinos, tipo eppendorf, da droga Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por Cocaína, e 98,74g (noventa e oito gramas e setenta e quatro decigramas) acondicionados em quatro porções da droga Tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis Sativa, L, conhecida vulgarmente como Maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de uma balança de precisão.

As circunstâncias em que os entorpecentes foram encontrados, bem como a quantidade de droga apreendida, somado às circunstâncias em que ocorreu a prisão dos réus, e à anterior denúncia nos autos de nº 1500087-72.2021.8.26.0218, da 2ª Vara Judicial desta Comarca, demonstram que seriam destinadas ao consumo de terceiros. Não bastasse, os acusados não indicaram motivação concreta para afastar a idoneidade da versão dos policiais.

Nesses termos, tem-se, inclusive, a afirmação do acusado Éder Marcelo de que parte da droga era destinada à mercancia. No mais, é certo que a prova pericial possibilitou conclusão no mesmo sentido, já que há inúmeras conversas no celular da acusada Patrícia com consumidores, no aplicativo WhatsApp, e uma conversa do acusado Éder, no aplicativo Facebook, sobre a venda de entorpecentes (fls.

134/141).

Posto isso, não é cabível a desclassificação do delito para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

No mais, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de que trata o artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, porquanto se vislumbra no caso a configuração do crime de associação para o tráfico, conforme será exposto mais adiante.

Confira-se a respeito, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 40, INCISOS V E VII, DO CP E DA AGRAVANTE DO ART. 62, INCISO I, DO CP NO CRIME DO ART. 35 DA LEI Nº

11.343/06. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º DA LEI

N. 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM A ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCURSO

MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE TRÁFICO PRATICADOS. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA

7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Rever os fundamentos utilizados pela Corte

a quo, para concluir pela ausência dos elementos necessários para a condenação pelo

crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente,

importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,

segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. Não há qualquer ilegalidade na aplicação da

agravante do art. 62, inciso I, do CP no crime de associação criminosa, uma vez que

a reprimenda do referido condenado foi aumentada pelo fato de organizar a

cooperação no crime de tráfico de drogas e dirigir a atividade dos demais agentes.

Ademais, a referida agravante não encontra-se dentro do tipo do crime previsto no

art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de

praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput

e § 1º, e 34 desta Lei), isto porque na associação para o tráfico seus integrantes

ocupam funções diversas, não sendo todos "líderes" do grupo. 3. A aplicação do

aumento previsto no art. 40, incisos V e VII, da Lei n. 11.343/2006 ao crime de

associação criminosa decorre da literalidade da lei (Art. 40. As penas previstas

nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se: [...] V -

caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito

Federal; [...] VII - o agente financiar ou custear a prática do crime), não se

podendo falar em ilegalidade. 4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é

no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da

Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de

diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a

dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1035945/RJ, Rel.

Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim,

mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei

n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista

no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 5. No presente caso, a Corte local entendeu que

o modo de execução dos delitos de tráfico foi distinto, bem como a forma de

atuação, o lugar e os envolvidos, de maneira a afastar o preenchimento dos

requisitos objetivos e subjetivos necessários ao reconhecimento da ficção jurídica

do crime continuado. Dessa forma, para se concluir de maneira diversa, como requer

a parte agravante, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório,

o que encontra óbice no disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental não

provido." (AgRg no AREsp 1293358/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,

QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019) - grifo nosso.

Quanto ao crime de associação para o tráfico, tem-se que o quadro probatório produzido nos autos permite a segura conclusão quanto à associação estável dos acusados para a prática delitiva, já que havia uma estrutura coesa e estável para a prática do crime.

Depreende-se das conversas extraídas dos celulares apreendidos (fls. 134/141), que

há uma organização entre os envolvidos no delito. Conforme as conversas, há de se

concluir que Patrícia e Éder guardavam e comercializavam os entorpecentes juntos.

As mensagens mostram que os acusados, em associação, venderam drogas de 21/08/2020

até 23/02/2021 (fl. 135).

A conduta descrita no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 vem representada pelo verbo

"associar", que significa agregar-se, unir-se. Essa associação, no entanto, deve

observar um mínimo de estabilidade. Não se confunde, assim, com o mero concurso de agentes.

O crime de associação somente se caracteriza quando ocorre estabilidade e permanência entre os agentes, circunstância que restou devidamente demonstrada pela prova colhida dos celulares apreendidos.

Tal qual o crime de associação criminosa, a associação para a traficância exige elo perene e estruturado entre agentes para a prática do crime. O de associação em especial para o crime de tráfico. É delito autônomo e dispensa até a prova do tráfico, suficiente a finalidade da associação. Porém, inadmissível que toda e qualquer comparsaria para a prática delituosa, quando provada, aponte objetivamente a responsabilidade por tal delito autônomo, sendo imprescindível a prova da perene associação entre os sujeitos, com a finalidade específica da traficância.

A conclusão encontra-se respaldada pelo entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em situações análogas:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CONFIGURADA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. 1. As materialidades e as autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na posse dos réus. Circunstâncias do caso concreto indicam a narcotraficância. A respeito do crime de associação para o tráfico (art. 35, "caput", da Lei n. 11.343/06), este restou configurado, posto que presentes os elementos caracterizadores da infração penal, quais sejam, o número de agentes (seis pessoas), a estabilidade ou permanência, e o liame subjetivo entre os réus para a prática do crime. Isso demonstra serem eles integrantes de uma estrutura muito bem organizada de narcotraficantes que visa ao estabelecimento de uma "clientela" no local, por meio da distribuição dos entorpecentes. 2. Depoimentos dos policiais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3. Dosimetria das penas estabelecida de modo correto. 4. Não há que se falar no reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porque os réus se dedicam a atividades criminosas, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, 03 tijolos de "cocaína" (pesando 3.150 gramas), 07 sacolas plásticas contendo "cocaína" (pesando 11.650 gramas), 01 sacola plástica contendo "maconha" (pesando 2.750 gramas), 03 sacolas plásticas contendo "maconha" (pesando 2.350 gramas), 03 pacotes contendo "cocaína" (pesando 428 gramas), 05 pacotes plásticos contendo "crack" (pesando 1.446 gramas) e 01 tijolo de "maconha" (pesando 780 gramas), além de duas peneiras, cinco balanças de precisão, sete bacias de plástico, diversos sacos plásticos para embalagem, um liquidificador, uma marreta, diversas embalagens de "eppendorfs", objetos estes característicos da prática do narcotráfico, bem como três cadernos contendo anotações referentes à venda de drogas, estão a evidenciar que não estavam, por mero acaso, a praticar o crime de narcotráfico. Isto porque, a própria quantidade de substâncias entorpecentes que eles guardavam e tinham em depósito, não há negar-se, vincula-os a um esquema maior de prática criminosa narcotraficante, a evidenciar que eles se dedicam às atividades criminosas, tanto assim que também condenados pela prática de crime de associação para o tráfico. Afinal, quem a elas não se dedica não conseguiria, sem mais nem menos, estar em poder dessa acentuada quantia de substâncias entorpecentes, voltadas à venda, vindo os réus a ser o elo final de toda uma cadeia criminosa, os encarregados, justamente, da disseminação, propriamente dita, das substâncias entorpecentes, que de mais a mais não consta fossem por eles produzidas, de modo que, necessariamente, como acima adiantado, estão eles inseridos na ponta final de uma corrente criminosa, sem se olvidar tratar-se o réu Orlando Pereira de reincidente na prática de crimes. Precedentes do STF. 5. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de narcotráfico será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido

conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. 6. Do mesmo modo, o regime inicial para o cumprimento da pena pelo crime de associação para o tráfico será o fechado, porém, autonomamente em relação ao tráfico de drogas, dadas as circunstâncias do caso concreto (natureza e a quantidade das drogas apreendidas. 7. Improvimento do recurso defensivo. "(TJ-SP - APL: 01032692220118260050 SP 0103269-22.2011.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 21/05/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 18/06/2015).

Em virtude do concurso material entre os delitos, as penas serão somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Inviável, por conseguinte, a absolvição vez que a prova é francamente hostil aos acusados.

Estabelecidas essas premissas quanto à análise da materialidade, autoria e tipicidade, passo, então, à dosimetria da pena, com atenção às funções preventiva e repressiva da sanção penal e observância do princípio da individualização da pena, nos termos do artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Na primeira etapa, apesar de o réu Éder Marcelo ostentar ANTECEDENTES criminais (fls. 160/163 e 164/168), estes serão analisados na segunda fase da dosimetria, como reincidência, a fim de se evitar o bis in idem. A ré Patrícia possui bons antecedentes. No mais, lhes são favoráveis as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, uma vez que agiram com CULPABILIDADE normal à espécie; não há elementos nos autos para aferir a sua PERSONALIDADE ou CONDUTA SOCIAL; os MOTIVOS, as CIRCUNSTÂNCIAS e as CONSEQUÊNCIAS são inerentes ao delito; não há que se apreciar acerca do COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. Não por outra razão, fixo a pena-base em seu patamar mínimo abstratamente previsto, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes; e 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o delito de associação para o tráfico, e aplico as penas para ambos os réus.

Na segunda etapa da dosimetria, presente a agravante genérica da reincidência para o acusado Éder Marcelo (proc. 0000188-72.2010 - fl. 160), motivo pelo qual aumento a pena em 1/6 (um sexto) para todos os crimes. Pena definida, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes; e 03 (três) anos e 06 (seis) meses e o pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa para o delito de associação para o tráfico.

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, vez que o acusado Éder confessou parcialmente, tentando excluir a prática do crime de associação para o tráfico, que restou comprovada pelas provas nos autos. Ainda, consoante Enunciado nº 630 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. E, nesse ponto, o acusado alegou que era usuário de drogas e as vendia para manter o vício, o que enseja a aplicação do aludido enunciado.

No que tange a ré Patrícia não há agravantes ou atenuantes a serem apreciadas nessa fase da dosimetria, motivo pelo qual mantenho a pena fixada na etapa anterior.

Na terceira fase, porque ausentes quaisquer causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitivas as reprimendas fixadas nos estágios anteriores para os réus.

Por fim, em virtude do concurso material entre os delitos, na forma do artigo 69 do Código Penal, somo as penas anteriormente fixadas, totalizando 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa para o réu Éder Marcelo de Oliveira Lopes; e 08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa para a ré Patrícia Alves Lameu. O dia-multa é fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), devidamente atualizado, à míngua de provas sobre as condições econômicas

dos réus.

A respeito da fixação do regime inicial e a possibilidade de substituição por restritiva de direitos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que fixam o regime inicial fechado obrigatoriamente e que obstam a substituição da pena por restritiva de direitos para o delito de tráfico, pelo que devem ser observados os critérios gerais do Código Penal, conforme aresto que segue:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. REEXAME A SER FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.1. Não competia ao Tribunal de Justiça do Acre, em julgamento de recurso exclusivo da defesa, complementar a sentença para acrescentar fundamento novo, não utilizado pelo juízo de primeiro grau, a fim de justificar a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.2. Este Supremo Tribunal Federal assentou serem inconstitucionais a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena, em se tratando de tráfico de entorpecente. Precedentes.3. Recurso parcialmente provido para determinar que o juízo da Vara de Delitos e Tóxicos e Acidentes de Trânsito da Comarca de Rio Branco reexamine dos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para a fixação do regime prisional, afastadas as vedações dos arts. 33, § 4º, e 44, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990.” (STF Processo RHC 120416 AC Órgão Julgador Segunda Turma Publicação DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 Julgamento 24 de Junho de 2014 Relator Min. CÂRMEN LÚCIA).

Para início de cumprimento de pena, norteado pelos critérios previstos no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para ambos os réus.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública e, em consequência, condeno, como incursos no artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, sob os consectários da Lei nº 8.072/90:

a) ÉDER MARCELO DE OLIVEIRA LOPES, qualificado nos autos, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal;

b) PATRÍCIA ALVES LAMEU, qualificada nos autos, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e o pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O montante da pena obsta a concessão dos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Autorizo, desde já, a destruição de entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para novos exames e decreto a perda em favor da União, dos objetos e valores apreendidos, que serão revertidos diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63 e § 1º, da Lei 11.343/06.

“Status Libertatis”:

Nego ao réu Éder Marcelo o direito de recorrer em liberdade, valendo, a presente deliberação, para os fins do artigo 316, parágrafo único, do CPP. Isto porque, diante da gravidade em concreto do delito (reconhecida pela sentença proferida nesta data), permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva (fls. 87/93).

O réu aguardou o julgamento preso, nada justificando que agora, quando certa a responsabilidade criminal, seja solto, inclusive porque poderia frustrar o cumprimento da pena ora imposta. Ademais, o réu é reincidente. Assim, porque presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, incabível a concessão de liberdade provisória ao acusado. Recomende-se.

Expeçam-se as guias de execução provisória.

Com relação à ré Patrícia, considerando que o E. Tribunal de Justiça do estado de São Paulo concedeu ordem de Habeas Corpus (fls. 314/318), sob o fundamento de inexistir o fumus boni iuris, o periculum in mora e as condições de admissibilidade

da prisão preventiva, concedo a ré o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver custodiada.

Transitada em julgado:

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe.

Expeçam-se certidões de honorários em favor dos Defensores Dativos, consoante termos e valores do Convênio OAB/Defensoria Pública.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais (artigo 804 do CPP), suspensa a exigibilidade, porquanto lhes concedo o benefício da justiça gratuita.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Guararapes, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA